

0000965-22.2022.8.26.0126

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GLAUCIA FERNANDES PAIVA

Comarca: São Sebastião

Foro: Foro de São Sebastião

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/09/2022

... do Estado de São Paulo:

"APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - PROVA - SUFICIÊNCIA - Materialidade e autoria comprovadas - Réu preso em flagrante - Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecente TESTEMUNHO POLICIAL - VALIDADE - O testemunho dos policiais tem validade como qualquer outro - Depoimentos coerentes - DESCLASSIFICAÇÃO - USO PRÓPRIO - INVIABILIDADE - A ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Sebastião

Foro de São Sebastião

Vara Criminal

Rua Emidio Orselli, 333, Sao Sebastiao - SP - cep 11600-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000965-22.2022.8.26.0126 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000965-22.2022.8.26.0126 - Controle nº 2022/000685

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Michael de Jesus da Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GLAUCIA FERNANDES PAIVA

Vistos.

Nos termos da denúncia juntada às fls. 102/103, no dia 15 de março de 2022, por volta das 22h12min, na Rua Passagem da Servidão, bairro Camburi, nesta cidade e Comarca de São Sebastião/SP, MICHAEL DE JESUS SILVA OLIVEIRA, qualificado à fl. 02, trazia consigo 06 (seis) papелotes com cocaína, com peso bruto de 09g (nove gramas); 01 (uma) porção grande de maconha, com peso bruto de 51g (cinquenta e uma gramas); além da importância de R\$ 20,00 (vinte reais); conforme auto de exibição e apreensão de fl. 12, auto de constatação preliminar de fl.13 e laudo pericial definitivo de fls. 175/177.

Em razão destes fatos, MICHAEL DE JESUS SILVA OLIVEIRA, qualificado à fl. 02, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Preso em flagrante delito, com fundamento nos artigos 282, 310, II e 312, do Código de Processo Penal, o réu teve sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva (fls. 75/78).

Recebida a denúncia (fls. 123/124), o réu foi citado (fls. 132) e apresentou

resposta à acusação (fls. 135/137). O recebimento da denúncia foi ratificado (fls. 141/145). Designada audiência, em instrução foi procedido ao interrogatório do réu e colhido o depoimento de duas testemunhas arroladas pelas partes (fls. 181/183). Em debates, o Ministério Público pugnou pela procedência da pretensão punitiva, entendendo provados os fatos narrados na denúncia, ao passo que a Defesa, sustentando insuficiência de provas, requereu a improcedência da pretensão punitiva estatal, em conformidade com o art. 386, V, do Código de Processo Penal, aduzindo que o acusado admitiu que as drogas que estavam em seu poder eram destinadas ao consumo pessoal dele. Subsidiariamente, postulou pela desclassificação do delito previsto no art. 33, caput, para o crime previsto no art. 28, ambos da Lei nº 11.343/2006. Subsidiariamente, na hipótese de condenação, requereu que a pena base seja fixada no mínimo legal. Requereu a aplicação da atenuante da confissão espontânea, caso seja considerada a confissão informal perante os policiais, compensando-se com a agravante da reincidência. Quanto ao regime, pugnou pela sua fixação de acordo com a quantidade de pena a ser aplicada, requerendo, também, a fixação de regime semiaberto.

Nada requereram as partes na fase do art. 402 do CPP.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Não há preliminares.

No mérito, o pedido inserto na denúncia é procedente.

A materialidade se evidenciou pelo auto de prisão em flagrante de fl. 02, pelo boletim de ocorrência de folhas 02/06, pelo auto de exibição e apreensão de fl. 13, auto de constatação preliminar de substância entorpecente de fl. 14, imagens de fls. 34/37, relatório final de fls. 92/93, laudo de exame químico-toxicológico de fls. 175/177, que revelou resultado positivo para a presença de "maconha" e "cocaína", bem como pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A autoria é igualmente certa e repousa sobre a pessoa do réu. Senão vejamos:

Na fase inquisitiva (fl.09), o réu MICHAEL DE JESUS SILVA OLIVEIRA preferiu manter-se calado.

Em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o réu MICHAEL negou a prática delitiva. Informou que reside na cidade de Itapevi e que estava em cumprimento de pena, em regime aberto. Na ocasião dos fatos, veio até esta cidade, trazendo consigo sua filha, a fim de deixá-la na residência da avó dela. No percurso, na cidade de Bertioga, adquiriu entorpecentes (06 pinos de "cocaína", 30g de "maconha"). Ato contínuo, deixou a criança na residência da avó e se dirigiu de ônibus até o bairro de Camburi, pois iria permanecer na residência de seu irmão por uma semana. Ao desembarcar foi abordado pelos policiais militares que localizaram consigo os entorpecentes, tendo o interrogando afirmado aos policiais que tais drogas eram destinadas ao seu consumo pessoal. Admitiu que possui passagens na Vara da Infância e por tal razão é conhecido no meio policial, todavia, nega a traficância e afirma que está sendo acusado injustamente. Nega, ainda, que é "dono de biqueira". Afirmou que trabalha como Funileiro, bem como que estava cumprindo a pena de forma esmerada. Ao Ministério Público respondeu: afirmou que a droga apreendida consigo - 30g de "maconha" e 6 pinos de "cocaína" - eram destinadas ao seu consumo; não tem conhecimento da procedência do restante da droga. À Defensora respondeu: na adolescência, quando tinha 16 anos de idade, nesta cidade, foi acusado de ter efetuado disparos de arma de fogo contra um policial, durante a fuga em um assalto, e que o PM Rodinilson sabia disso, bem como, nas dependências da Delegacia de Polícia, na data dos fatos, tal policial divulgou esta informação. O policial militar, Ronaldo da Silva, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, narrou, em síntese, que: na data dos fatos, realizava patrulhamento ostensivo pelo bairro Camburi, momento em que avistaram o acusado. Salientou que tinham conhecimento de que havia um mandado de prisão expedido em desfavor dele. Disse que Michael ao perceber a aproximação da viatura tentou empreender fuga, mas foi contido. Questionado, informalmente, Michael admitiu que as drogas que trazia consigo seriam destinadas ao tráfico, pois iri vendê-las em uma festa que estava ocorrendo no "Villa Show Cambury". O acusado admitiu, ainda, que o produto obtido

com a venda dos entorpecentes seria utilizado para comprar mais drogas e reativar as "biqueiras" dele. Tinham ciência da existência de uma mandado de prisão expedido em desfavor do acusado e que o mesmo estaria "rodando pelo bairro". O réu trazia consigo papelotes de "cocaína" e "maconha" a granel. Disse que o réu já é conhecido nos meios policiais, por uma tentativa de homicídio contra um policial e por tráfico de drogas. Não abordou o réu anteriormente. A Defensora respondeu: não o abordou anteriormente; quando o réu avistou a viatura tentou empreender fuga; ao avistarem o réu, o identificaram, por já ser conhecido nos meios policiais.

No mesmo sentido foram os relatos do policial militar Rodinílson Santos de Souza, em nada divergindo o depoimento de ambos. A Defensora respondeu: após a prisão do acusado, o mesmo foi conduzido à Delegacia de Polícia; no ato da abordagem reconheceu o acusado, que já é conhecido nos meios policiais.

Pois bem.

As declarações do réu não demonstraram harmonia com a dinâmica dos fatos comprovados nos autos. A versão dada por ele é dissonante do que fora apurado durante a instrução criminal.

Vejam os:

O réu, em juízo, afirmou que reside em Itapevi/SP e que trouxe a filha para visitar a avó. Salientou que, no trajeto, adquiriu drogas para seu consumo. Após deixar a filha com a avó, embarcou em um ônibus com destino ao bairro de Camburi, local em que reside o irmão dele. Assim que desceu do ônibus foi abordado e revistado pelos policiais, que localizaram consigo os mencionados entorpecentes. Alegou que tais policiais o conheciam, pois, em sua adolescência, nesta cidade, foi acusado de ter efetuado disparos de arma de fogo contra um policial, o que acredita ter motivado os policiais a forjarem o flagrante e a lhe acusarem injustamente. Afirmou, por fim, que exerce atividade lícita como Funileiro.

Percebe-se, no discurso, o nítido intuito de eximir-se da responsabilização penal, razão pela qual a versão por ele apresentada não pode ser aceita.

Perante a autoridade policial preferiu se calar acerca dos fatos. Tampouco, utilizou-se dos meios disponíveis para denunciar os policiais, ainda que de forma anônima, teriam forjado drogas para lhe incriminar. Além disso, o réu também poderia ter registrado um boletim de ocorrência delatando o ilícito, supostamente cometido pelos mesmos policiais, mas não o fez. Ressalte-se que o réu disse que trouxe sua filha à residência da avó dela; que permaneceria na casa de seu irmão por uma semana, porém, sequer os arrolou para confirmar sua versão. Disse que exerce a atividade lícita de funileiro e, mais uma vez, não comprovou sua alegação. Alega que as drogas eram destinadas ao seu consumo e, novamente, não comprovou - por qualquer meio de prova - seu suposto vício em drogas. Como se não bastasse, verifica-se da análise da certidão de distribuições criminais (fls. 55/58) e da folha de antecedente (fls. 46/54) que o autuado é reincidente, bem como estava em regime aberto por ocasião do flagrante (Proc. de Exec. nº 0001319-73.2015.8.26.0520).

A doutrina majoritária entende que:

"Cabe provar a quem tem interesse em afirmar. A quem apresenta uma pretensão cumpre provar os fatos constitutivos; a quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas. A prova da alegação (onus probandi) incumbe a quem a fizer (CPP, artigo 156, caput). Exemplo: cabe ao Ministério Público provar a existência do fato criminoso, da sua realização pelo acusado e também a prova dos elementos subjetivos do crime (dolo ou culpa); em contrapartida, cabe ao acusado provar as causas excludentes da antijuridicidade, da culpabilidade e da punibilidade, bem como circunstâncias atenuantes da pena ou concessão de benefícios legais". GN

Por outro lado, os policiais militares, uníssonos, narraram os fatos em conformidade com as provas dos autos. O PM Silva afirmou que efetuavam patrulhamento pelo bairro Camburi, quando avistaram o acusado, que já é conhecido nos meios policiais, e este, ao perceber a aproximação da viatura policial tentou empreender, sem sucesso, fuga do local. Afirmou que o acusado Michael,

informalmente, confessou que as drogas que trazia consigo seriam destinadas ao tráfico, pois iri vende-las em uma festa que estava ocorrendo no "Villa Show Cambury". O acusado confessou, ainda, que o produto obtido com a venda dos entorpecentes seria utilizado para comprar mais drogas e reativar as "biqueiras" dele. No mesmo sentido, foram os relatos do PM Souza. Não há dúvidas, portanto, sobre a conduta criminosa do acusado diante das provas produzidas. Os policiais prestaram depoimentos coesos, em conformidade com as provas dos autos, sob o crivo do contraditório e gozam de idoneidade, especialmente porque não se demonstrou que os policiais tivessem interesse concreto de incriminar indevidamente o réu, de modo que seus depoimentos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação.

Vê-se, pois, que os depoimentos dos policiais ouvidos em juízo confirmaram a prática do delito de tráfico de drogas e estão em consonância com os demais elementos constantes dos autos, não havendo que se falar em falta de provas. Ademais, nada há que pudesse, ainda que superficialmente, colocar em dúvida a lisura do trabalho policial, pelo que o decreto condenatório é solução inevitável. Ressalte-se que não há nos autos qualquer elemento idôneo hábil a retirar a credibilidade do testemunho policial.

Presume-se a lisura dos agentes públicos, pois investidos no cargo para segurança pública. Seria paradoxal o Estado atribuir a tais pessoas a execução de um ato administrativo de polícia preventiva e repressiva, mas não aceitar sua palavra na valoração das provas. Tal raciocínio vem sendo aplicado há muito tempo na jurisprudência geral, com ressonância no Supremo Tribunal Federal (HC 87.662-PE, Rel. Min. CARLOS BRITO, j.5.9.06) e no Superior Tribunal de Justiça (REsp. 151.150-SC, Rel. Min. JOSÉ DANTAS, j. 7.4.98).

No mesmo sentido a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - PROVA - SUFICIÊNCIA - Materialidade e autoria comprovadas - Réu preso em flagrante - Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecente TESTEMUNHO POLICIAL - VALIDADE - O testemunho dos policiais tem validade como qualquer outro - Depoimentos coerentes - DESCLASSIFICAÇÃO - USO PRÓPRIO - INVIABILIDADE - A quantidade da droga apreendida, sua forma de acondicionamento e as circunstâncias em que se deu a prisão são fatores que, associados à prova produzida, levam à certeza de que o réu efetivamente se dedicava à mercancia de entorpecentes - PENA - MULTA - QUANTUM - INCONSTITUCIONALIDADE - INOCORRÊNCIA - O preceito secundário do crime de tráfico ilícito de drogas não fere os princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena - A quantidade da pena de multa cominada ao tipo penal em questão guarda relação com sua gravidade - Opção de política criminal adotada pelo legislador no combate ao tráfico ilegal de entorpecentes - Julgador que, no momento do cálculo da pena, deverá observar as especificidades do caso concreto - Condenação mantida- RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO" (TJSPAp.n. 0084921-43.2010.8.26.0000 - 15ª Cam. Direito Criminal Rel. AMADO DE FARIA j. 16.12.2010) - gn.

Oportuno lembrar que, para a configuração do crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando, como na espécie, que o agente tenha em depósito a substância entorpecente. Já decidiu o STF: "A noção de tráfico ilícito de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização". (HC 69.806/00 Rel. Min. Celso de Melo in. DJU 04.06.1993, p. 11012).

Além disso, a quantidade das drogas apreendidas, a confissão informal do acusado aos militares; as contradições e a inércia do réu no sentido de provar suas alegações (onus probandi - CPP, artigo 156, caput), evidenciam que as drogas eram destinadas ao consumo de terceiros, não havendo falar-se em insuficiência probatória. Saliente-se que o réu é reincidente.

Incabível a desclassificação da conduta para a de posse de entorpecentes para consumo pessoal, devendo o réu ser condenado pelo crime de tráfico de drogas, pois suficientes as provas de materialidade e autoria delitivas. Ademais, a quantidade de entorpecentes apreendidos em poder do acusado revela que as drogas não se

destinavam ao consumo pessoal dele. Frise que o acusado não comprovou ser usuário de drogas, tampouco que já foi submetido a tratamento por conta disso e, por fim, sequer arrolou alguém para corroborar tal afirmativa.

Diante de todo o exposto, resta, enfim, a fixação das penas, porquanto inexistem circunstâncias excludentes da ilicitude ou que isentem o réu de sanção.

Na primeira fase, da análise da certidão de distribuições criminais (fls. 55/58) e da folha de antecedente (fls. 46/54) verifica-se que o réu ostenta mais de uma condenação com trânsito em julgado. Assim, uma delas (818-49.2014 - Roubo majorado) utilizo nesta fase de aplicação da pena na qualidade de maus antecedentes, elevando a pena base em 1/6, tornando-a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Não é o caso de aumento da pena em razão da quantidade e variedade de entorpecente apreendido, na medida em que a situação do caso concreto, a meu ver, não desborda do que é esperado ordinariamente nos crimes de tráfico de entorpecentes.

Na segunda fase de aplicação da pena, observo que o réu é reincidente (fls. 55/58), motivo pelo qual exaspero a pena em 1/6, tornando-a em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa. Não há que se falar em aplicação da atenuante da confissão extrajudicial, já que o réu permaneceu calado na fase inquisitiva e negou a traficância em juízo, não cabendo a aplicação de tal instituto com base na confissão informal aos milicianos que, por sua vez, é irrelevante frente ao farto conjunto probatório. Nesse sentido; "A referência feita pelos militares à confissão informal, como simples narrativa da operação que redundou na prisão do apelante, não enseja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea" (TJ-MG - APR: 10701190162555001 MG, Relator: Dirceu Walace Baroni, Data de Julgamento: 07/05/2020, Data de Publicação: 11/05/2020).

Na terceira fase, deixo de aplicar a causa de diminuição de pena, prevista no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, sendo o réu multirreincidente, bem como estava em regime aberto por ocasião do flagrante (Proc. de Exec. nº 0001319-

73.2015.8.26.0520), assim, não faz jus ao benefício. Mantida, portanto, a pena fixada na fase anterior, qual seja, 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

O regime inicial será o fechado, sendo o adequado ao cumprimento de pena, diante da reincidência e da quantidade de pena aplicada, na forma do artigo 33, do Código Penal. Nesse sentido: "O regime inicial fechado é o adequado para o cumprimento da pena de 5 anos de reclusão, em razão da aferição negativa de circunstância judicial, que justificou o aumento da pena-base, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal". STJ, HC 444200/RJ, Quinta Turma, rel.Min. Ribeiro Dantas, julgado em 14/08/2018, DJe 23/08/2018.

Não é caso de conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, pois ausentes seus requisitos, considerando a quantidade de pena aplicada e a reincidência (Art. 44, I e II, CP). Pelo mesmo motivo, sobretudo pela quantidade de pena aplicada, não há que se falar em suspensão condicional da pena (Art. 77, CP). Inexistindo informações sobre o elemento subjetivo necessário à progressão de regime, bem como considerando a quantidade de pena aplicada e o tempo de prisão provisória cumprida pelo acusado, não há detração a ser procedida no momento, para fins de determinação de regime inicial mais brando, nos termos da Lei 12.736/2012. Para tanto, remeto à VEC a aplicação do art. 387, §2º, CPP.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e, em consequência CONDENO: MICHAEL DE JESUS SILVA OLIVEIRA, qualificado nos autos, à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, de valor unitário mínimo legal, no regime prisional inicial fechado por infração ao artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. Fixa-se cada dia-multa no valor mínimo unitário legal, diante da falta de informações precisas sobre a situação econômica do réu. Oportunamente, intime-se para pagamento das multas.

Denego ao acusado o direito de apelar em liberdade. Ele permaneceu preso durante a instrução em razão de prisão em flagrante convertida em preventiva, pois concorrentes os motivos ensejadores da prisão preventiva. De fato, o delito de

tráfico possui grande perniciosidade social, o qual está sempre associado a uma organização criminosa, em maior ou menor grau de proximidade, e com desdobramentos em outros crimes. Assim, a custódia cautelar do réu é necessária para a garantia da ordem pública. Aliás, se antes do julgamento de mérito que considerou o acusado culpado estava cautelarmente recolhido, com mais lógica assim deve permanecer após a condenação – TJSP, MS 113.332-3, Rel. Reynaldo Ayrosa. Ademais, há risco concreto de reiteração delitiva, considerando ser multirreincidente em crime doloso.

Recomende-se o acusado na prisão onde está recolhido.

Expeça-se guia de recolhimento provisória caso haja recurso interposto por qualquer das partes, encaminhando-a ao Juízo das Execuções Criminais competente e recomende-se o acusado na prisão onde está recolhido.

O réu não apresentou prova da origem lícita do dinheiro com ele apreendido, razão pela qual decreto a sua perda e determino a destinação direta ao FUNAD, nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06. Expeça-se o necessário.

Oficie-se à Delegacia autorizando a destruição das drogas apreendidas.

Condene o réu a arcar com as custas judiciais, nos termos do artigo 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, apenas suspensa a obrigatoriedade de quitação porque anotada gratuidade, a qual resta deferida, nos termos do artigo 13, da Lei 1.060/50.

Sem prejuízo da expedição do necessário para intimação pessoal do réu, expeça-se o necessário quanto aos valores, aparelho celular e às drogas.

Cumpra-se

P.I.C.

Sao Sebastiao, 29 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA